

学生A及びBは、次の【事例】に関して、後記【会話】のとおり議論している。学生A及びBが後記【会話】の後も議論を続けた場合、後記1から5までの各【発言】のうち、学生Aの発言であると考えられるものを選びなさい。

【事例】

甲は、酒の力を借りて妻Vを殺害しようと決意し、心神喪失状態に陥る可能性があることを認識しながら、自宅において手元に包丁を用意して大量に飲酒し、その結果、心神喪失状態に陥り、計画どおり同包丁でVを刺突して殺害した。

【会話】

学生A. 私は、【事例】について飲酒行為を実行行為と捉え、甲に殺人罪が成立し、完全な刑事責任を問うことができると考えます。

学生B. 私も、【事例】の甲に殺人罪が成立し、完全な刑事責任を問うことができると考えますが、Aさんの見解とは異なり、刺突行為を実行行為と捉えます。

【発言】

1. あなたの見解によると、結果発生の危険との関連性が希薄な行為を実行行為と捉えることになってしまいますか。
2. 私は、実行行為が完全な責任能力のある原因行為時における意思決定の実現であるといえれば、完全な刑事責任を問うことは可能であると考え、実行行為の時点で責任能力が存在することは必要ないと考えます。
3. あなたの見解は、【事例】の甲は責任能力のない自己を道具のように利用して殺人を実行したと考えるのですか。
4. あなたの見解によると、仮に【事例】の甲が飲酒して眠り込んでしまい、刺突行為を全く行わなかったとしても、殺人未遂罪が成立し得ることになりますが、それは不当ではないですか。
5. 私の見解によれば、実行行為の時点で責任能力が存在しなければならないとしつつ、【事例】の甲の可罰性を説明できます。

本件【事例】は、殺人をするため積極的に飲酒（原因行為）をして自ら心神喪失状態を招いて刺突行為（結果行為）を行ったという原因において自由な行為の事例である。

原因において自由な行為の理論については、原因行為時の責任能力を問題とし、かつ実行行為と責任能力の同時存在の原則を維持するために、原因行為を実行行為とする見解がある（構成要件モデル）。一方、実行行為はあくまでも結果行為であるとしつつ、実行行為と責任能力との同時存在の原則を修正し、責任非難の時点のみを原因行為までに遡らせる見解がある（責任モデル）。

【会話】における学生Aの発言から、学生Aは本件【事例】について原因行為である飲酒行為を殺人の実行行為と捉えており、構成要件モデルを採っているといえる。これに対し、学生Bは「Aさんの見解と異なり」として、刺突行為を実行行為と捉えているから、責任モデルを採っているといえる。

1 学生Bの発言

学生Aの見解によると、原因行為である飲酒行為を殺人罪の実行行為と捉えることになる。飲酒行為によって直接Vの死亡結果が生ずるわけではないため、結果発生の危険との関連性が希薄な行為を実行行為と捉えることになる。したがって、本発言は、学生Aの見解に対する批判であるため、学生Bの発言である。

2 学生Bの発言

学生Aの見解は、責任能力は実行行為の時に存在しなければならないという実行行為と責任能力の同時存在の原則を遵守するものである。本発言では、「実行行為の時点で責任能力が存在することは必要ない」として学生Aの見解を批判している。したがって、本発言は、学生Bの発言である。

3 学生Bの発言

本発言は、「あなたの見解は」と述べているため、発言者の相手方が原因において自由な行為の可罰性を間接正犯類似説で主張していることが考えられる。間接正犯類似説とは、行為者が故意又は過失によって自分自身を心神喪失に陥れ、その状態における身体的動静を道具のように利用して犯罪を実現するのが原因において自由な行為であるから、他人を道具として利用して犯罪を実現する間接正犯に類似するものとして捉える見解である。そして、原因において自由な行為においても、結果行為ではなく、責任無能力状態の自分を道具として利用しようとする原因行為を実行行為とみることができるとする。そうすると、原因行為を実行行為と捉えているのは学生Aであるから、本発言は、学生Bの発言である。

4 学生Bの発言

本発言は、「飲酒行為」を実行行為と捉える立場を批判するものである。「飲酒行為」を実行行為と捉えるのは学生Aであるから、本発言は、学生Aを批判する学生Bの発言である。

5 学生Aの発言

「飲酒行為」という原因行為を実行行為とすると、飲酒行為の時点では甲は責任能力を有していたのであるから、実行行為の時点で責任能力が存在しなければならないという実行行為と責任能力の同時存在の原則を遵守しつつ、【事例】の甲のような原因において自由な行為について完全な責任を問うことができる。「飲酒行為」を実行行為と捉えるのは学生Aであるから、本発言は、学生Aの発言である。